

1502103-12.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291290/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 21023883 - 03º D.P.

DIADEMA, 2291290 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Givanildo Santos de Oliveira

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502103-12.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291290/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 21023883 - 03º D.P.

DIADEMA, 2291290 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Givanildo Santos de Oliveira

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GIVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 05 e 14/16 está sendo processado

como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 10h00, na Travessa Divinópolis, altura do nº 10, bairro do Canhema, nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 25 embalagens plásticas contendo 16,0g da droga cocaína, 38 embalagens plásticas contendo 4,0g da mesma droga, na forma de crack, e 62 embalagens plásticas contendo 66,0g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 18/19 e laudo de constatação provisória de fls. 20/23, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.40/43), o réu foi notificado e citado (fls. 80), e apresentou defesa preliminar as fls.84/86, através do Defensor Público que lhe foi nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 31/01/2022 (fl. 88).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, a ser agravada pela reincidência, sem se considerar a confissão do réu, já que parcial, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade, devendo os valores apreendidos serem perdidos, por proveniente do tráfico.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória ou de desclassificação para o crime do art. 37 da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.18/19, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.20/23 e 123/125), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha, bem como do laudo das anotações da contabilidade do tráfico (fls.121/122).

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls.2/4), efetuavam patrulhamento ostensivo quando ao realizarem incursão na Travessa Divinópolis, altura do numeral 10, Bairro Canhema, Diadema/SP avistaram um indivíduo mexendo em uma sacola plástica que estava em um muro baixo, sendo certo que o indivíduo ao perceber a presença policial demonstrou inquietude e nervosismo e imediatamente largou a sacola e evadiu-se correndo do local. Proferiram voz de parada ao indivíduo, que não atendeu ao comando e continuou a correr, e após percorrer cerca de 10 metros foi detido, sendo posteriormente identificado Givanildo Santos De Oliveira. Procedida a busca pessoal em Givanildo Santos De Oliveira, localizaram na sua posse, no interior do bolso de sua calça a quantia de R\$105,00 em espécie e um aparelho celular, marca Samsung. Retornaram ao local em que Givanildo Santos abandonou a sacola plástica antes de sair correndo e localizada a sacola,

procederam à busca em seu interior sendo localizado a quantia de R\$ 20,00 em espécie, uma folha de papel com anotações típicas de contabilidade de tráfico de drogas, 62 tabletes de erva esverdeada com características de Maconha, 25 invólucros plásticos contendo substância em pó branca com características de Cocaína, 38 invólucros plásticos contendo pedras amareladas com características de Crack. Indagaram informalmente Givanildo Santos De Oliveira, que afirmou que estava traficando drogas naquele local desde as 07hs da manhã e ganharia R\$ 250 por turno trabalhado.

Sob o crivo do contraditório o policial Thiago da Silva Ré confirmou que o réu, por si reconhecido, estava com uma sacola contendo drogas, dinheiro e anotações, e com ele também havia mais dinheiro. Ele confessou o tráfico de drogas. Assim que os viu, largou a sacola, foi seguido e detido. Reconhece o réu. Ele foi detido sozinho e não detiveram mais ninguém, pois ele estava mexendo na sacola quando o viu, antes dele correr.

Igualmente o policial Gustavo Teixeira reiterou que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. O réu mexia numa sacola. Ele os viu e saiu correndo, dispensando alto. Foi abordado e em busca pessoal localizaram dinheiro com ele. Questionado o que havia soltado antes de correr, ele confessou estar traficando desde cedo por estar precisando de dinheiro. Retornaram ao local e pegaram a sacola plástica com os três tipos mais comuns de drogas, em bastante quantidade. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local. Ele foi detido sozinho e não abordaram mais ninguém nessa diligência.

O réu, em solo policial (fl. 5) disse que estava vendendo drogas na Rua Santa Cruz quando foi surpreendido e detido por uma guarnição da PM.

Em juízo o acusado disse que realmente estava trabalhando no dia, como olheiro. Não tinha contato com a droga. Era só o fogueteiro. Quando os policiais chegaram, saiu andando e largou o rojão. Eles fizeram uma varredura e acharam as drogas. Acabou assumindo para não indicar o traficante e para não prenderem um outro rapaz que não tinha nada a ver. O escrivão perguntou o preço das drogas e respondeu porque sabe, já que também é usuário.

Logo, a confissão, ainda que parcial, não é prova única e veio corroborada pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

No mais, ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, mas as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar, ter em depósito e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de eventual situação de pobreza, pois segundo os policiais, o réu lhes disse estar traficando por necessitar de dinheiro, dado que os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de

perigo abstrato. Ademais, não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Assim como o desemprego não é motivo para excludente de ilicitude de tráfico. Admitir o contrário seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável.

A condição de usuário de drogas alegada pelo réu hoje, além de não ter vindo provada, não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação.

Diante de todo o exposto acima, afastado pedido defensivo de desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 37 da Lei Antidrogas, pois não restou provado que o réu estivesse em poder de um mero rojão, ou que seria apenas o olheiro, até porque essa versão não foi por ele ventilada desde solo policial, o que é no mínimo estranho. Ademais, foram apreendidos dinheiro, anotações (fls. 121/122), drogas diversas em grande quantidade, e se fossem de outra pessoa que teria conseguido fugir, certamente teria fugido com a sacola contendo todo o exposto antes. Até porque nem o réu nem a Defesa comprovaram que outro rapaz tenha sido detido com aquele e dispensado por ele ter assumido sozinho o tráfico. Enfim, a Defesa não comprovou o álibi do réu nem sua versão trazida hoje, como lhe competia o ônus dessa prova. Assim, e como visto, o contexto probatório indica que o réu estava no local efetivamente traficando as drogas, ainda que a ação policial não tenha sido filmada, pois isso ainda não é possível na comarca de Diadema. E como o acusado foi quem trouxe versão diferente hoje, sem comprova-la, entendo ser mais um indício de que pretende se ver condenado por delito com punição mais branda, apenas.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (125 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o dinheiro apreendido (fl. 51/52), assim como as anotações da contabilidade do tráfico (fl. 121/122) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável, ainda que a ação policial não tenha sido filmada, ou ainda que não tenha havido denúncia anônima acerca do réu ser o traficante do dia naquele local e ainda que não tenha sido feita campana, já que a prova indica que era o réu quem portava, trazia consigo e era o responsável pelos entorpecentes e sua venda, tanto que mexia na sacola onde eles estavam, e não fez prova do contrário.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (125 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fl. 30/31 - Condenação definitiva pelo art. 37 da Lei Antidrogas proferida na 3ª Vara Criminal de Diadema) a qual compenso com a atenuante da confissão, ainda que parcial prestada hoje, uma vez que confessou informalmente aos policiais e reiterou sua confissão perante a autoridade policial, prova esta também considerada a embasar a condenação, de modo que a pena resta inalterada nesta etapa, ainda que nesta data

tenha tentado fazer crer ser mero olheiro/fogueteiro.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente também pela prática de crime previsto na Lei de Drogas, a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional fechado, considerando a quantidade da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no RESp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário). Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em que pese a

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão

inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GIVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 05 e 14/16, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual n.º 11.608 de 2003.

Decreto a perda de numerário apreendido (fl.18/19 e 51/52), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).
Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA